

Vulnerabilidade na era digital: um estudo sobre os fatores de vulnerabilidade da pessoa natural nas plataformas, a partir da dogmática do Direito do Consumidor

Claudia Lima MARQUES*

Guilherme MUCELIN**

“O ponto de partida do CDC é a afirmação do Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo, o que não quer dizer compactuar com exageros que, sem utilidade real, obstem o progresso tecnológico, a circulação dos bens de consumo e a própria lucratividade dos negócios” (REsp 586.316/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17/04/2007, DJe 19/03/2009)

RESUMO: Objetiva-se com este capítulo clarificar novos fatores de vulnerabilidade decorrentes do comércio eletrônico e da utilização de plataformas a partir da dogmática de direito do consumidor. Emprega-se o método dedutivo, com abordagem documental, jurisprudencial e doutrinária. Conclui-se que as pessoas naturais são vulneráveis no ambiente digital.

PALAVRAS-CHAVE: Consumo digital; vulnerabilidade estrutural; vulnerabilidade por *design* e por tratamento de dados pessoais; vulnerabilidade situacional; vulnerabilidade por catividade.

SUMÁRIO: Introdução; – 1. Fatores tradicionais de vulnerabilidade do consumidor aplicados ao digital; – 1.1. Vulnerabilidades técnica e jurídica/científica; – 1.2. Vulnerabilidades fática e informacional; – 2. Fatores especiais de vulnerabilidade/fraqueza dos consumidores no digital; – 2.1. Vulnerabilidade digital estrutural: por *design* e tratamento de dados pessoais; – 2.2. Vulnerabilidade digital situacional: por catividade/dependência ou neuropsicológica; – Considerações finais.

TITLE: *Vulnerability in the Digital Age: a Study on the Vulnerability Factors of the Natural Person on Platforms, Based on the Dogmatics of Consumer Law*

ABSTRACT: *The objective of this chapter is to clarify new vulnerability factors arising from electronic commerce and the use of platforms, based on consumer law dogmatics. The deductive method is used, with a documentary, jurisprudential and doctrinal approach. It is concluded that persons are vulnerable in the digital environment.*

* Professora Titular e Diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Professora Permanente do PPGD da mesma instituição. Doutora em Direito pela Universidade de Heidelberg. Mestre em Direito pela Universidade de Tübingen. Relatora-geral da Comissão de Juristas do Senado Federal para a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Presidente do Comitê de Proteção Internacional do Consumidor da *International Law Association*. ORCID: 0000-0001-9548-0390.

** Doutorando e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; especialista em Direitos Fundamentais e Direito do Consumidor pela UFRGS; especialista em *Droit comparé et européen des contrats et de la consommation* pela Université de Savoie Mont Blanc/UFRGS; especialista em Direito do Consumidor pela Universidade de Coimbra, com bolsa do CDEA. Pesquisador do Grupo de Pesquisa CNPq “Mercosul, Direito do Consumidor e Globalização”. Coordenador acadêmico dos cursos de pós-graduação *lato sensu* em “o Novo Direito Internacional” e “O Novo Direito do Consumidor”. Bolsista CAPES. Premiado pelo CDEA com estada na Alemanha e com período de estágio doutoral na Universidade Nova de Lisboa/Portugal (Bolsa CAPES). ORCID: 0000-0003-3709-6539.

KEYWORDS: *Digital consumption; structural vulnerability; vulnerability by design and data-driven; situational vulnerability; vulnerability by captivity.*

CONTENTS: *Introduction; – 1. Traditional consumer vulnerability factors applied to digital; – 1.1. Technical and legal/scientific vulnerabilities; – 1.2. Factual and informational vulnerabilities; – 2. Special factors of vulnerability/weakness of digital consumers; – 2.1. Structural digital vulnerability: by design and processing of personal data; – 2.2. Situational digital vulnerability: by captivity/addiction or neuropsychological; – Final considerations.*

Introdução

Vulnerabilidade remete à ideia de fragilidade e necessidade de proteção¹. *Vulnus* é ferida, *vulnerare* é ferir, daí que vulnerabilidade (*vulnerabilis*)² é a situação, a possibilidade, ou o *status* daquele que tem uma fraqueza, susceptibilidade e pode ser ferido; vulnerável é o mais fraco, o que perdeu ou nunca teve a possibilidade de se defender.³

Nos últimos anos, a doutrina, no Brasil⁴ e no mundo,⁵ tem alertado para o agravamento da vulnerabilidade do consumidor na era digital, especialmente frente as novas formas

¹ COHET-CORDEY, Frédérique (org.). *Vulnerabilité et droit: le développement de la vulnérabilité et ses enjeux en droit*. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2000, Preface, p. 9.

² FIECHTER-BOULVARD, Frédérique. La notion de vulnérabilité et sa consécration par le droit. In: COHET-CORDEY, Frédérique (org.). *Vulnerabilité et droit: le développement de la vulnérabilité et ses enjeux en droit*. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2000. p. 14, nota 5.

³ MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. *O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, 25.

⁴ Veja, por todos, MIRAGEM, Bruno. Princípio da vulnerabilidade: perspectiva atual e funções no direito do consumidor contemporâneo. In: MIRAGEM, Bruno; MARQUES, Claudia Lima; DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães (org.). *Sociedade de consumo, proteção do consumidor e desenvolvimento: comemoração dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor*. São Paulo: GEN: Forense, 2020, p. 233-261; e MIRAGEM, Bruno. Novo Paradigma tecnológico, mercado de consumo digital e o direito do consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, vol. 125/2019, p. 17 – 62, Set - Out / 2019: “O desenvolvimento tecnológico que transforma o mercado de consumo, desse modo, não afasta os preceitos fundamentais do direito do consumidor que o disciplina. Ao contrário, tende, em muitas situações, a confirmar o próprio fundamento de seu surgimento, e critério de interpretação e aplicação de suas normas: a vulnerabilidade do consumidor, que frente às novas tecnologias da informação pode ser agravada pelo desconhecimento de seus aspectos técnicos ou mesmo a incapacidade de acompanhar a velocidade das inovações. Veja também: DO CANTO, Rodrigo Edelwein. Direito do consumidor e vulnerabilidade no meio digital. *Revista de Direito do Consumidor*, vol. 87/2.013, p. 179 – 210, maio -jun / 2013.

⁵ Veja, por todos, HELBERGER, N.; SAX, M.; STRYCHARTZ, J.; MICKLITZ, H.-W. Choice Architectures in the Digital Economy: Towards a New Understanding of Digital Vulnerability, *Journal of Consumer Policy*, dez. 2021, p. 1-26. Como escrevemos: “a noção de vulnerabilidade digital descreve o poder e a capacidade de atores comerciais de afetarem decisões, desejos, necessidades e comportamentos de uma maneira que o consumidor tende a não tolerar, mas também não está em posição de impedir. Serve, assim, para delinear um estado universal de indefesa e de suscetibilidade à *exploração* de desequilíbrios por parte do parceiro que em algum sentido é mais forte, o que é favorecido pela automação do mercado de consumo, pela sua arquitetura, pela utilização de dados pessoais e pela concentração das funções de gerenciamento e de condução da dimensão digital em plataformas.” (MUCELIN, Guilherme. Navegar (online) é preciso, viver (offline) não é preciso: o preenchimento dinâmico e descritivo do conteúdo da vulnerabilidade digital. *Nova Consumer Lab*, 29 abr. 2022. Disponível em: <https://novaconsumerlab.novalaw.unl.pt/author/guilherme-mucelin/>. Acesso em: 7 set. 2022).

de marketing e ofertas,⁶ de contratos,⁷ de discriminações,⁸ assédio⁹ e de coleta de dados nas plataformas digitais,¹⁰ a exigir a atualização do CDC pelo PL 3514/2015.¹¹ Muitos autores brasileiros já mencionam expressamente, como Fernando Martins e Thainá Lima, a existência de uma nova ‘vulnerabilidade digital’ do consumidor.¹²

Em uma visão macro, a mudança seria oriunda da fase atual do capitalismo e mercado. Peter Hall e David Soskice defendem que existem muitas variedades de capitalismo.¹³ Srnicek¹⁴ argumenta que o capitalismo, quando em crise, tende a se reestruturar. Novas tecnologias, novas formas de organização, novos tipos de trabalho, novos mercados, novos modelos de negócios e novos modos de exploração surgem para que seja criada uma renovada maneira de acumular capital. O regime econômico do século XXI, o qual denominou de *capitalismo de plataforma*, seria centrado na extração e na utilização de dados, especialmente, por plataformas conectadas à internet. Aceitando esta premissa já destacamos em estudos prévios, que esta mudança econômica e social favorece o

⁶ Assim como Carvalho e Sousa resumem: “[a] vulnerabilidade do consumidor é agravada em virtude das circunstâncias sociais e das técnicas de marketing utilizadas pelos fornecedores que se aproveitam da psicopolítica digital, uma forma de controle social silencioso que estimula que as pessoas voluntariamente passem a demonstrar as suas preferências e a sua rotina. Os dados dos consumidores são armazenados e utilizados para ocasionar estímulos, criar necessidades para o indivíduo, no intuito de provocar novas contratações e aumentar o lucro.” (CARVALHO, Alexander Perazo Nunes de; SOUSA, Raphaella Prado Aragão de. A influência da psicopolítica digital nas contratações virtuais e seus reflexos no aumento da vulnerabilidade do consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, vol. 123/2019, p. 289 – 309, Maio - Jun /2019, p. 289).

⁷ Veja, por todos, MARQUES, Claudia Lima; JOELSONS, Marcela. *Smart contracts* e a autoexecutabilidade: a necessária proteção do consumidor através do PL 3514/2015. In DE LUCCA, Newton; LIMA, Cíntia Rosa. *Direito e Internet IV*. São Paulo: Quartier Latin, 2022 (no prelo).

⁸ Veja, por todos, BERGSTEIN, Laís. TRAUTWEIN, José Roberto Della Tonia. Desafios da tutela da pessoa com deficiência no comércio eletrônico. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, n. 125, set.-out. 2019. p. 84 e seg.

⁹ Assim BORGES, Gustavo; FILÓ, Maurício da Cunha Savino. Consumo, publicidade e inteligência artificial: (necessários) limites à tecnologia persuasiva no constante assédio do consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, vol. 136/2021, p. 201 – 232, Jul - Ago / 2021.

¹⁰ Assim MIRAGEM, Bruno. *Curso de Direito do Consumidor*. 8. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 159 e seg.

¹¹ No mesmo sentido também AZEVEDO, Fernando Costa de; SANTOS, Karinne E. G. dos.; MOREIRA, Tássia Rodrigues. Vulnerabilidade dos consumidores na sociedade da informação e necessidade da proteção jurídica de seus dados nas relações estabelecidas em ambiente digital. *Revista de Direito do Consumidor*, vol. 141/2022, p. 201 – 218, Maio - Jun / 2022, p. 217-218: “...com o advento das novas tecnologias, faz-se necessária a ampliação dos mecanismos legais de tutela do consumidor. Por isso, a aprovação do PL 3514/2015, que trata do comércio eletrônico, é de extrema relevância para a regulação dessa forma de contratação tão utilizada na sociedade de consumo contemporânea, de modo a proporcionar a sua proteção.”. Veja AZEVEDO, Fernando Costa de; KLEE, Antonia Espíndola Longoni. Considerações sobre a proteção dos consumidores no comércio eletrônico e o atual processo de atualização do Código de Defesa do Consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, n. 85, p. 209- 260, jan.-fev. 2013.

¹² MARTINS, Fernando Rodrigues; LIMA, Thainá Lopes Gomes Lima. Da vulnerabilidade digital à curiosa “vulnerabilidade empresarial”, *Revista de Direito do Consumidor*, vol. 128/2020, p. 119 – 161, Mar - Abr / 2020g., p. 119 e seg.

¹³ HALL, Peter A. ; SOSKICE, David. An Introduction to Varieties of Capitalism. In HALL, Peter A.; SOSKICE, David (Eds.). *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundation of Comparative Advantage*. Oxford University Press, 2001, p. 1-2.

¹⁴ SRNICEK, Nick. *Platform capitalism*. Cambridge: Polity Press, 2017.

aparecimento de novos fornecedores (*gatekeepers*)¹⁵ na relação de consumo, assim como a inovação de novas formas de consumo,¹⁶ mas dificultam a governança estatal,¹⁷ que passa a depender cada vez mais da atuação de grandes ‘players’ da economia global,¹⁸ à procura da eficiência da proteção do direito do consumidor no mundo digital.

A internet é uma hiper arquitetura sob a qual foi construído o espaço digital, espécie de ambiência em que se edificou e se constituiu a extensão da realidade física e abstrata por meio de representações de seres, de instituições e de lugares, normalmente na forma de dados e de códigos computacionais e desafio o direito.¹⁹ Nesse sentido, Zuboff²⁰ observa que os elementos fundamentais da civilização – linguagem, bens culturais, tradições, instituições, regras e leis – seguiram essa tendência, posto que estão sendo digitalizados e pela primeira vez transcritos explicitamente em código visível, retornando ao tecido social na forma de algoritmos inteligentes que são utilizados com o propósito de conduzir uma série de funções sociais, governamentais e comerciais.

Como adverte Hoffmann-Riem,²¹ a penetração da tecnologia em todos os setores da sociedade dá causa ao entrelaçamento das áreas *online* e *offline*, tornando o digital uma estrutura básica quase que onipresente utilizada para os mais diversos fins, o que chamou de *on-life*: um novo tipo de mundo que está começando a se formar. Nesse novo mundo em específico, a totalidade das relações são ou serão mediadas, viabilizadas ou concretizadas *por intermédio de* ou *com* plataformas, em cuja estrutura ressalta-se a importância dos códigos, compreendidos também os algoritmos. Esses elementos,

¹⁵ Veja MARQUES, Claudia Lima. A nova noção de fornecedor no consumo compartilhado: um estudo sobre as correlações do pluralismo contratual e o acesso ao consumo. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 111, p. 247-268, maio/jun. 2017; e MARQUES, Claudia Lima. Perspectives for consumer protection in the XXI century. *Macau Journal of Brazilian Studies*, Macau, v. 4, n. 1, Abr. 2021, p. 73-86.

¹⁶ Veja a obra oriunda do 17th Congresso da IACL-International Association of Consumer Law em Indianápolis, WEI, Dan; NEHF, James P.; MARQUES, Claudia Lima. *Innovation and the Transformation of Consumer Law*, Springer-SSAP, Cham, 2020, em especial BUDNITZ, Mark E. Principles and Programs to Protect consumers from the Deleterious Effects of Technological Innovation, in WEI, Dan; NEHF, James P.; MARQUES, Claudia Lima. *Innovation and the Transformation of Consumer Law*, Springer-SSAP, Cham, 2020, p. 3-18.

¹⁷ Veja sobre a atividade privada das empresas deste novo capitalismo que afeta o direito do consumidor: MARQUES, Claudia Lima; MARCELLO BAQUERO, Pablo. Governança global e direito do consumidor. In MARQUES, Claudia Lima; MARTINI, Sandra Regina; FINCO, Matteo (org.). *Diálogos entre Direitos Humanos, Direito do consumidor, Compliance e Combate à corrupção*. Belo Horizonte: YK Ed, 2021. p. 108-109.

¹⁸ Veja a sugestão de um UN Consumer Global Compact e pacto semelhante no Mercosul, in MARQUES, Claudia Lima, DAN, Wei. Report Lisbon Congress 2022, acessível in *Int_Protection_of_Consumers_Interim_Report_2022.pdf* (ila-hq.org) e ILA Res. 7/2022. Disponível em: [ccpb_IGECON_Resolution_Lisbon_ILA_en.pdf](#) (unctad.org). Acesso em: 12 set. 2022.

¹⁹ Veja, por todos: MARQUES, Claudia Lima; MUCELIN, Guilherme. Transformação digital no Brasil: Estrutura jurídica para a promoção da confiança. In: THEMOTEO, Reinaldo J. (Org.). *Reavivando e reforçando os diálogos entre Brasil e Europa*. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2021. p. 187-202.

²⁰ ZUBOFF, Shoshana. *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. New York: Public Affairs, 2019.

²¹ HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. *Teoria geral do direito digital: transformação digital, desafios para o Direito*. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

conforme Lessig,²² atuam na regulação e na modulação dos comportamentos dos sujeitos ao lado das normas jurídicas e das convenções sociais, o que altera também o mundo analógico.

São interações recíprocas: relações *online* modificam relações *offline* e vice-versa, fazendo com o que o ambiente digital e o “real” tenham a si atribuída certa simbiose, que pode ser identificada a partir dos objetos (produtos/serviços inteligentes), dos sujeitos (perfis de consumo e de trabalho), da estrutura (virtual) e das relações ali estabelecidas.²³

Em outra oportunidade, já havíamos identificado a interrelação e interdependência entre o consumo digital e o consumo analógico, o qual denominamos de *mercado de consumo simbiótico*,²⁴ cujo principal elo entre as estruturas físicas e as digitais são os dados, dentre os quais os dos consumidores.

Como resultado, Zuboff²⁵ afirma que tanto o mundo quanto nossas vidas estão sendo reproduzidos como informação. Como afirmamos,²⁶ o mundo digital de consumo é uma “medusa”,²⁷ onipresente pelo total acesso aos dados dos cidadãos-consumidores²⁸ e, nesse sentido, as vulnerabilidades dos sujeitos também o serão potencializadas por conta da ‘ambiência’ e ‘omnipresença’ digital.

²² LESSIG, Lawrence. *Code*: version 2.0. New York: Basic Books, 2006.

²³ Veja MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. Serviços simbióticos ou inteligentes e proteção do consumidor no novo mercado digital: homenagem aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. *Revista do Advogado sobre os "30 anos do Código de Defesa do Consumidor"*, p. 14-29.

²⁴ “Identificamos o *consumo simbiótico* pelas interrelações entre os agentes econômicos – consumidores e fornecedores – e entre eles e os objetos circundantes que captam a ‘realidade’ e a transformam em atributos virtuais na forma de dados. Em outros termos, é a interação constante entre o digital e o analógico, do consumidor pessoa natural com o consumidor-perfil-titular de dados, de serviços/produtos inteligentes e dos modos *ominichannel* de contratação” (MARQUES, Claudia Lima; MUCELIN, Guilherme. Novo mercado de consumo ‘simbiótico’ e a necessidade de proteção de dados dos consumidores. In: SARLET, Gabrielle Bezerra Sales; TRINDADE, Manoel Gustavo Neubarth; MELGARÉ, Plínio. *Proteção de dados: temas controvertidos*. Indaiatuba: Foco, 2021. p. 67-94, p. 72)

²⁵ ZUBOFF, Shoshana. *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. New York: Public Affairs, 2019.

²⁶ WEI, Dan; NEHF, James P.; MARQUES, Claudia Lima (Eds.). *Innovation and the Transformation of Consumer Law*, Singapura: SSAP-Springer, 2020, p. v e seg.

²⁷ A figura de linguagem é de: BAUDRILLARD, Jean. *La société de consommation*. Paris: Denoël, 1970. p. 17.

²⁸ Sobre a mudança digital como uma mudança de valor dos “dados”, de uma economia de escassez de dados para uma economia de plataformas, com hiperabundância de dados e Big data, veja: SCHWEITZER, Heike. *Digitale Plattformen als private Gesetzgeber: ein Perspektivwechsel für die europäische “ Plattform-Regulierung”*, *ZEUP* 1 (2019) 1-12, p. 1-2.

Inspirados pelos estudos de Hans-W. Micklitz,²⁹ os quais avaliam que o desafio de futuro do direito do consumidor será refinar o conceito de vulnerabilidade, de modo a permitir analisar todos os modos pelos quais os consumidores podem ser afetados pelos atores, pela estrutura ou arquitetura dos mercados digitais.

Nosso objetivo é, então, analisar os principais fatores de vulnerabilidade/fraqueza das pessoas naturais nas plataformas a partir da dogmática do Direito do Consumidor, que há muito desenvolve o tema.³⁰ Este estudo que foi dividido em duas grandes partes: a primeira se dedica a revisitar fatores “tradicionais” da vulnerabilidade no mercado de consumo analógico, fazendo correlações com o consumo digital; e a segunda, a seu turno, prestando-se a avaliar o reconhecimento de novas e especializadas vulnerabilidades que o consumo (mais que) digital (simbiótico) dá causa. Vejamos.

1. Fatores tradicionais de vulnerabilidade do consumidor aplicados ao digital

Fineman³¹ destaca que humanos são seres sociais, isto é, dependem *de* e se inserem *em* relações e instituições ao longo da vida. Exige-se, como fator constante, algum tipo de conjunto de relações sociais e de estruturas institucionais, muito embora uma e outra variem no decorrer do tempo por conta de mudanças no contexto social. Assim, a abordagem acerca da vulnerabilidade possibilita argumentar que o Estado deve ser responsivo, ou seja, deve responder às realidades da vulnerabilidade humana, bem como às situações que refletem desigualdade.

Ao Direito, a noção de vulnerabilidade está associada à identificação de uma fraqueza/debilidade do sujeito em determinada relação jurídica decorrente de condições ou qualidades que lhe são inerentes, a uma posição de força identificada no outro sujeito, à confrontação injustificada de interesses no mercado ou, ainda, às diversas situações às

²⁹ Veja, em especial: ADAM, Leonie; MICKLITZ, Hans-W. Verbraucher und Online-Plattformen, in MICKLITZ et alli (Hrsg.). *Verbraucherrecht 2.0 – Verbraucher in der digitalen Welt*, Nomos: Baden-Baden, 2017, p. 45-102; e HELBERGER, N.; SAX, M.; STRYCHARTZ, J.; MICKLITZ, H.-W. Choice Architectures in the Digital Economy: Towards a New Understanding of Digital Vulnerability, in *Journal of Consumer Policy*, (Dez 2021), p. 1 do original: “Digital vulnerability, we argue, is architectural, relational, and data-driven.”

³⁰ Havíamos privilegiado, em outra oportunidade (MARQUES, Claudia Lima; MUCELIN, Guilherme. Novo mercado de consumo ‘simbiótico’ e a necessidade de proteção de dados dos consumidores. In: SARLET, Gabrielle Bezerra Sales; TRINDADE, Manoel Gustavo Neubarth; MELGARÉ, Plínio. *Proteção de dados: temas controvertidos*. Indaiatuba: Foco, 2021. p. 67-94), a nomenclatura de *cybervulnerabilidade* para destacar as vulnerabilidades advindas da ambiência *online*, em apreço à diferenciação que Lessig aborda no *The Code 2.0* entre ciberespaço e internet. Contudo, documentos internacionais abordam essa vulnerabilidade como digital, razão esta pela qual neste texto vamos abordar a vulnerabilidade com essa nomenclatura geral.

³¹ FINEMAN, Martha Albertson. Vulnerability and inevitable inequality. *Oslo Law Review*, Escandinávia, v. 4, n. 3-2017, 2017, p. 133-149.

quais são os sujeitos submetidos³². O princípio da vulnerabilidade está expressamente consignado no ordenamento jurídico brasileiro no art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e serve para explicar e guiar a aplicação do Direito do Consumidor e, de um modo geral, a proteção que é conferida a determinados sujeitos de direitos em situação de desigualdade³³.

Em relação ao consumidor, Hamilton, Dunnet e Piacentini definem vulnerabilidade como um estado permanente ou temporário indesejável, o qual é catalisado por diversas condições e contextos, com a capacidade de afetar a forma como o consumidor experiencia, interpreta e responde ao mercado e como o mercado a ele responde. Baker, LaBarge e Baker³⁴ conceituam vulnerabilidade como um estado dinâmico de impotência (*powerlessness*) e dependência originado a partir de estados individuais, características pessoais ou condições externas, dando causa a um desequilíbrio nas interações entre os agentes mercadológicos ou pela atividade de *marketing*.

Como mencionamos sempre, existem quatro tipos de vulnerabilidade: a técnica, a jurídica, a fática e, mais recentemente, a informacional,³⁵ a respeito das quais teceremos considerações também em relação ao mundo digital.

1.1. Vulnerabilidades técnica e jurídica/científica

A *vulnerabilidade técnica* é identificada quando o consumidor não detém conhecimentos específicos ou especializados sobre produtos e serviços, objetos da relação de consumo,³⁶ sua utilidade, seus componentes, o que lhes gravita ou sobre seus “efeitos colaterais”.³⁷ A desigualdade planta-se na relação jurídica com o fornecedor, nas lições de Miragem,³⁸ porque existirá uma presunção autorizada de que, ao realizar oferta de produtos ou serviços no mercado de consumo, detenha esse agente econômico maior

³² MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. *O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

³³ MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. *O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

³⁴ BAKER, Stacey Menzel; LA BARGE, Monica; BAKER, Courtney Nations. Consumer vulnerability: Foundations, phenomena, and future investigations. In: HAMILTON, Kathy; DUNNET, Susan; PIACENTINI, Maria (eds.). *Consumer vulnerability: conditions, contexts and characteristics*. London/New York: Routledge, 2016. p. 13-30.

³⁵ MARQUES, Claudia Lima. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor*. 9ª ed., São Paulo: RT, 2019, p. 310 e seg.

³⁶ MARQUES, Claudia Lima. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.p. 313.

³⁷ MORAES, Paulo Valério Dal Pai. *Código de Defesa do Consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade, na oferta, nas demais práticas comerciais*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009

³⁸ MIRAGEM, Bruno. *Curso de Direito do Consumidor*. 8. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. [e-book].

grau de informações – inclusive, essa é condição para que se atenda aos deveres de informação que lhe são imputados (art. 6º, III, CDC).

Configura-se, nesse sentido, a partir do reconhecimento do grau elevado de expertise e de profissionalidade do fornecedor, o qual determinará o desequilíbrio na relação de consumo em atenção ao *know-how* e às expertises necessárias desde a concepção até os métodos de *marketing* e o consequente escoamento da produção ao mercado consumidor. Como mencionamos,³⁹ esse tipo de vulnerabilidade é presumido para o consumidor não profissional, mas que pode, excepcionalmente, ser estendida aos consumidores profissionais ou pessoas jurídicas nas suas atividades empresariais, se comprovadamente existente, no caso concreto, algum tipo de vulnerabilidade (teoria finalista aprofundada⁴⁰).

Passando para as especificidades da ambiência virtual, é de se considerar⁴¹ que o meio eletrônico, automatizado e telemático, utilizado para o oferecimento de produtos e serviços, apresenta um desafio extra ou um complemento à vulnerabilidade técnica. Considera-se que o consumidor não é, nem mesmo por consideração, especialista ou experto em computadores, em sistemas de internet ou ciência de dados, por exemplo. A aceleração do digital com as plataformas, com a abundância de dados e com o uso da inteligência artificial aumenta esta vulnerabilidade.⁴²

Será, então, uma “falha tecnológica” geral, que também é caracterizada pela desmaterialização, desterritorialização e despersonalização dos contratos de consumo que daí se estabelecem. Aliás, Micklitz *et al.*⁴³ confirmam esse entendimento, ao estabelecer que a vulnerabilidade do consumidor no ambiente digital é geral, em

³⁹ MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.p. 313.

⁴⁰ Marques e Mucelin 2017.

⁴¹ MARQUES, Claudia Lima. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

⁴² MARQUES, Claudia Lima; MUCELIN, Guilherme. Inteligência artificial e “opacidade” no consumo: a necessária revalorização da transparência para a proteção do consumidor. In: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia. *O Direito Civil na Era da Inteligência Artificial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 411-439.

⁴³ MICKLITZ, Hans-W.; HELBERGER, Natali; STRYCHARZ, Joanna et al. *EU consumer protection 2.0: Structural asymmetries in digital consumer markets*. Bruxelas: BEUC, mar. 2021.

contraposição ao entendimento do *average consumer*⁴⁴ (consumidor médio) do padrão europeu.⁴⁵

Frise-se que, independentemente de haver uma contratação de um produto ou um serviço ou mesmo diminuição no patrimônio do consumidor em favor do *site* ou aplicativo,⁴⁶ acessado determinado portal, a relação de consumo se estabelece entre o provedor de aplicações (o fornecedor) e o consumidor que se utiliza desses serviços prestados, mesmo que referente ao simples acesso e navegação, ao mesmo tempo em que passam a incidir as normas de proteção aos dados dos quais é titular.

Atualmente, observa-se uma expansão da vulnerabilidade técnica do consumidor por conta de três razões que, de certa forma, encontram-se conexas. A primeira, como aventado, relaciona-se com o tratamento de dados pessoais dos consumidores titulares e com suas potenciais utilizações (ex. decisões automatizadas e perfilização), realizadas por tecnologias de ponta (ex. inteligência artificial e algoritmos “caixa-preta”⁴⁷), o que se dá em quase a totalidade das plataformas contemporaneamente.

A segunda razão reside no desenvolvimento de novos serviços digitais ou então simbióticos, fenômenos decorrentes da servicização. Elucidam Marques e Miragem⁴⁸ que se presencia uma nova fase no mercado de consumo, não só de produtos digitais como também de produtos inteligentes, isto é, aqueles que apresentam uma simbiose entre o

⁴⁴ Segundo Incardona e Poncibò: “*The average consumer test reflects the economists’ idealistic paradigm of a rational consumer in an efficient marketplace. This notion may be useful for economists’ calculations and projections but departs from the unpredictable realities of individual human behavior and is hardly an appropriate standard for legislative or judicial sanctions*”. (INCARDONA, Rossella; PONCIBÒ, Cristina. The average consumer, the unfair commercial practices directive, and the cognitive revolution. *Journal of consumer policy*, v. 30, n. 1, p. 21-38, 2007. p. 35).

⁴⁵ Sobre a influência do Direito Europeu no direito do consumidor no Brasil, veja: MARQUES, Claudia Lima; PFEIFFER, Roberto. Dissemination of Consumer Law and Policy in Brazil: The Impact of EU Law. In *Journal of Consumer Policy*, p. 1-22, 2022; e JAYME, Erik. Visões para uma teoria pós-moderna do direito comparado. In *Revista dos Tribunais* 759, p. 24-40, jan. 1999 (Trad. Claudia Lima Marques).

⁴⁶ Conforme já decidiu o STJ: “1. A exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei nº 8.078/90” e que: “2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo “mediante remuneração”, contido no art. 3º, § 2º, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor.” (STJ, REsp 1316921/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26/06/2012, DJe 29/06/2012).

⁴⁷ Pasquale assim define: “*The term “black box” is a useful metaphor for doing so, given its own dual meaning. It can refer to a recording device, like the data- monitoring systems in planes, trains, and cars. Or it can mean a system whose workings are mysterious; we can observe its inputs and outputs, but we cannot tell how one becomes the other. We face these two meanings daily: tracked ever more closely by firms and government, we have no clear idea of just how far much of this information can travel, how it is used, or its consequences*”. (PASQUALE, Frank. *The black box society*. Cambridge/London: Harvard University Press, 2015, p. 3).

⁴⁸ MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. “Serviços simbióticos” do consumo digital e o PL 3.514/2015 de atualização do CDC. 2020. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 132, p. 91-118, nov./dez. 2020.

produto em si e serviços, entre *hardware* e *software*, que incluem um serviço digital, em clara inspiração no Min. do STJ Antonio Herman Benjamin.⁴⁹

À terceira razão acrescenta-se como fator de complexidade, logo de maior grau de vulnerabilidade técnica do consumidor, os ambientes inteligentes, como os que serão propiciados pela Internet das Coisas quando suficientemente implementada nos diversos setores da sociedade. Há, nesse sentido, riscos a serem observados de diversificadas naturezas, dentre os quais se pode destacar a interligação de todos os aparelhos via internet, o que poderá ter efeito cascata em caso de vício ou defeito de algum componente isoladamente considerado por todo o ambiente e potencialmente causando danos ao consumidor mais relevantes e extrapolando o valor do produto/serviço em si.⁵⁰

Da mesma forma, outro aspecto da vulnerabilidade técnica reside na vulnerabilidade estrutural (não do consumidor, mas) dos próprios sistemas, cuja identificação se dará no tocante às suas fragilidades de segurança, especialmente em relação a ataques e invasões ilícitas.⁵¹ De fato, há uma crescente sofisticação tecnológica que desponta no mercado de consumo, o que aumenta, em termos jurídicos, também a vulnerabilidade.

Já a *vulnerabilidade jurídica*, sustenta Miragem,⁵² compreenderá a falta de conhecimento jurídico do consumidor pelos seus direitos e pelo que se obriga ou, em outros termos, dos direitos e deveres que caracterizam e qualificam a relação de consumo, bem como das condições e dos efeitos jurídicos do conteúdo do contrato que celebra. No ambiente digital, essa vulnerabilidade é ainda mais potencializada, na medida em que se constata que os consumidores não leem efetivamente os termos e condições de uso e demais documentos pertinentes, como as políticas de privacidade e de coleta e tratamento de dados, o que abre espaço para o cometimento de possíveis abusos.

⁴⁹ Inspirado no *decisum* do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Herman Benjamin. (STJ. REsp 1721669/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018).

⁵⁰ MARQUES, Claudia Lima. Contratos cativos de longa duração e a exceção da ruína: tempo, boa-fé, catividade e confiança. in _____; LORENZETTI, Ricardo Luis; CARVALHO, Diógenes Faria de; MIRAGEM, Bruno. *Contratos de serviços em tempos digitais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 447-488.

⁵¹ Assim Marques: “Note-se que a vulnerabilidade técnica é aumentada se a atividade é ilícita, como no caso dos jogos de bingos ou proibidos”. (MARQUES, Claudia Lima. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019).

⁵² MIRAGEM, Bruno. Princípio da vulnerabilidade: perspectiva atual e funções no direito do consumidor contemporâneo. In: _____; MARQUES, Claudia; MAGALHÃES, Lúcia Ancona. *Direito do Consumidor: 30 anos do CDC – da consolidação como direito fundamental aos atuais desafios da sociedade*. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 243-261.

Moraes⁵³ discorda desse posicionamento, já que, em seu entendimento, a vulnerabilidade que diz respeito à ausência ou à dificuldade de compreensão de aspectos jurídicos da relação de consumo e dos contratos pelo consumidor se enquadraria na técnica. O autor visualiza a vulnerabilidade jurídica ao adotar o momento em que o consumidor experencia algum problema de consumo até o momento em que houver o deslinde judicial, o que acarretaria dificuldades em saber, por exemplo, a quais órgãos se dirigir, o acesso à justiça, a mora do fornecedor em relação à urgência (muitas vezes) do consumidor em resolver sua questão, a habitualidade do litigante (fornecedor) que lhe daria uma certa vantagem e, podemos acrescentar, os desestímulos frequentes do Poder Judiciário a indenizar os prejuízos suportados pelos consumidores que, em quantidade considerável de casos, são reduzidos a *mero dissabor*.⁵⁴

Aliada à jurídica, sempre mencionamos⁵⁵ a *vulnerabilidade científica* em paralelo, enfatizando que se daria nos mesmos moldes, porém com outras ciências, como a economia e a contabilidade, que seriam imprescindíveis aos contratos de crédito, por exemplo. Percebe-se que esta presunção (relativa às pessoas jurídicas) também é fonte irradiadora de deveres de informação sobre o conteúdo contratual em face da complexidade das relações conexas e de vínculos múltiplos e cativos, bem como do dever de comunicação do conteúdo do contrato residente na sua redação de forma clara e ostensiva. Explica-se, por conta também desse tipo de vulnerabilidade do consumidor, os vários deveres informacionais reforçados dos fornecedores de crédito constantes na nova Lei 14.181/2021, que atualiza o CDC.⁵⁶

Parece-nos que a vulnerabilidade científica, referente àquelas ciências ligadas à transformação digital, também poderão bem explicar e guiar a aplicação do CDC e da

⁵³ MORAES, Paulo Valério Dal Pai. *Código de Defesa do Consumidor*: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade, na oferta, nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

⁵⁴ BERGSTEIN, Laís. *O tempo do consumidor e o menosprezo planejado*. São Paulo, RT, 2019, p.38 e seg.

⁵⁵ MARQUES, Claudia Lima. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor*: o novo regime das relações contratuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

⁵⁶ Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Art. 54-B. No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no art. 52 deste Código e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou o intermediário deverá informar o consumidor, prévia e adequadamente, no momento da oferta, sobre: I - o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem; II - a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos, de qualquer natureza, previstos para o atraso no pagamento; III - o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser, no mínimo, de 2 (dois) dias; IV - o nome e o endereço, inclusive o eletrônico, do fornecedor; V - o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do § 2º do art. 52 deste Código e da regulamentação em vigor. § 1º As informações referidas no art. 52 deste Código e no caput deste artigo devem constar de forma clara e resumida do próprio contrato, da fatura ou de instrumento apartado, de fácil acesso ao consumidor. § 2º Para efeitos deste Código, o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor, sem prejuízo do cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro. § 3º Sem prejuízo do disposto no art. 37 deste Código, a oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo, ou a fatura mensal, conforme o caso, devem indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar, com e sem financiamento.

LGPD nas relações digitais e, em especial, nas questões envolvendo tratamento de dados pessoais dos consumidores e o comércio eletrônico em geral, onde se engendram as plataformas.

Há de destacar-se aqui o Projeto de Lei n. 3514/2015, que pretende atualizar do Código de Defesa do Consumidor exatamente em atenção ao mercado de consumo digital, nacional e internacional e, em muito, inspirado nas Diretivas europeias.⁵⁷ Como afirmamos, se fosse aprovado com o texto que foi aprovado em 2015 no Senado Federal, o PL 3514/2015 já seria um grande avanço.⁵⁸ A pergunta atual⁵⁹ é se necessitaria ser revisitado para que consiga fazer frente aos novos desdobramentos de consumo, bem como às situações em que qualidades subjetivas dos consumidores tornam-se métricas objetivas para orientar a atividade comercial dos fornecedores.

1.2. Vulnerabilidades fática e informacional

Continuando esse raciocínio, traz-se a *vulnerabilidade fática*. Conforme Miragem,⁶⁰ é uma espécie ampla que abrangerá, de modo genérico, numerosas situações concretas de reconhecimento da fragilidade do consumidor por conta de suas qualidades subjetivas, as quais denotam uma subordinação estrutural ao fornecedor. Ensina que essa vulnerabilidade poderá tomar lugar a partir de um aspecto relativo ao porte econômico das partes, que se refletirá na desproporção dos meios de defesa de seus interesses, bem como do exercício de suas pretensões.

Sempre consideramos⁶¹ a vulnerabilidade fática como socioeconômica, pois o ponto de concentração será o outro parceiro contratual que, por conta da sua superioridade econômica, da essencialidade do seu serviço/produto ou da sua posição de monopólio, impõe a sua superioridade a todos que estabeleçam com ele contratos de consumo. No

⁵⁷ MARQUES, Claudia Lima; PFEIFFER, Roberto. Dissemination of Consumer Law and Policy in Brazil: The Impact of EU Law. In *Journal of Consumer Policy*, vol. 45, p. 27–48, 2022. p. 27 e seguintes.

⁵⁸ MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. “Serviços simbióticos” do consumo digital e o PL 3.514/2015 de atualização do CDC. 2020. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 132, p. 91-118, nov./dez. 2020. E, republicado, in _____; LORENZETTI, Ricardo Luis; CARVALHO, Diógenes Faria de; MIRAGEM, Bruno. *Contratos de serviços em tempos digitais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 391-424.

⁵⁹ MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. “Serviços simbióticos” do consumo digital e o PL 3.514/2015 de atualização do CDC. 2020. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 132, p. 91-118, nov./dez. 2020. E, republicado, in _____; LORENZETTI, Ricardo Luis; CARVALHO, Diógenes Faria de; MIRAGEM, Bruno. *Contratos de serviços em tempos digitais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 391-424.

⁶⁰ MIRAGEM, Bruno. *Curso de Direito do Consumidor*. 8. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. [e-book].

⁶¹ MARQUES, Claudia Lima. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

mesmo sentido Moraes,⁶² para quem esse tipo de vulnerabilidade (na menção do autor seria econômica e social) decorre diretamente da desproporção de forças existente entre o consumidor e os demais agentes econômicos, de modo que se torna facilitado a eles impor sua vontade. Defende também que a conjuntura econômica do país influencia nesses aspectos, como grandes crises e que, na esteira do professor, podemos citar contemporaneamente a crise advinda da pandemia de coronavírus,⁶³ da mesma forma que, em tempos de retração econômica, os variados acidentes da vida que podem resultar em superendividamento.

Contudo, consoante Miragem,⁶⁴ esse tipo de vulnerabilidade ultrapassa o aspecto econômico para alcançar um nível existencial. Na exata medida em que qualidades subjetivas são identificadas, como já se referiu, poderá existir uma sobreposição de critérios para fundamentar a vulnerabilidade agravada do consumidor, como nos casos de se tratar de relações estabelecidas com crianças, idosos, pessoas com deficiência, enfermos etc., os quais podem se tornar suscetíveis aos apelos e às práticas comerciais dos fornecedores. Lado outro, verifica-se essa vulnerabilidade igualmente em circunstâncias fáticas concernentes à relação, como o consumidor doente que contrata planos de saúde ou nas hipóteses de contratação de consumidores analfabetos ou não falantes do idioma utilizado para a concretização de determinada relação de consumo, o que viria a demandar, como se tem defendido, um dever de cuidado especial.

Existe ainda outro tipo de vulnerabilidade. Consideramos⁶⁵ como a básica dos consumidores e, assim, intrínseca à relação de consumo, a *vulnerabilidade informacional* ganhou contornos próprios, separando-se, em termos de análise, das outras. É que a informação, atualmente, representa o maior fator de desequilíbrio das relações de consumo – ao ponto de Calais-Auloy e Temple⁶⁶ considerarem o déficit informacional entre consumidor e fornecedor a principal vulnerabilidade –, já que os fornecedores, além de serem profissionalizados e possuírem conhecimentos específicos

⁶² MORAES, Paulo Valério Dal Pai. *Código de Defesa do Consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade, na oferta, nas demais práticas comerciais*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

⁶³ Sobre o início da pandemia e o papel do direito do consumidor, veja: MUCELIN, Guilherme; D'AQUINO, Lúcia Souza. O papel do direito do consumidor para o bem-estar da população brasileira e o enfrentamento à pandemia de COVID-19. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 129, p. 17-46, maio/jun. 2020; veja também: RIEFA, Christine. Coronavirus as a catalyst to transform consumer policy and enforcement. *Journal of consumer policy*, v. 43, n. 3, p. 451-461, 2020.

⁶⁴ MIRAGEM, Bruno. Princípio da vulnerabilidade: perspectiva atual e funções no direito do consumidor contemporâneo. In: _____; MARQUES, Claudia; MAGALHÃES, Lúcia Ancona. *Direito do Consumidor: 30 anos do CDC – da consolidação como direito fundamental aos atuais desafios da sociedade*. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 243-261

⁶⁵ MARQUES, Claudia Lima. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

⁶⁶ CALAIS-AULOY, Jean; TEMPLE, Henri. *Droit de la consommation*. Paris: Daloz, 2010. p. 55

a respeito do produto ou do serviço, bem como dos meios de oferta e contratação, são os que efetivamente decidem quais as que serão suficientes para serem repassadas ao consumidor de modo a atender os seus deveres informacionais constantes no CDC.

A falta ou o excesso de informação, nesse sentido Miragem,⁶⁷ dá conta de uma maior dificuldade de o consumidor considerar (e mais, compreender) todo o plexo informacional e dele retirar as que são relevantes para a contratação ou então no que diga respeito ao objeto da relação, o produto ou o serviço.

As informações, a marca e as comunicações despertam a confiança no consumidor,⁶⁸ sujeito confiante passivo que, em princípio, não tem condições de atestar veracidade dos dados ou então a existência de informações outras que não foram fornecidas, mas que, outrossim, seriam de extremada importância. Miragem ensina “nesta perspectiva, informação é um poder, e a imposição do dever de informação aos fornecedores visa, em última análise, promover a equidade informacional das partes”.⁶⁹

Posto de outra forma, a falta e/ou o excesso de informação se constituem em novos riscos, cujos teores serão preenchidos em acordo com o bem de consumo em si considerado, com as características próprias de determinada relação ou do próprio contrato. Informar significa colaborar, compartilhar, tornar comum, situar e, como consequência, empoderar o consumidor para que sua vontade seja realmente refletida acerca das decisões de consumo: é uma forma de manutenção e de criação de confiança e é alicerçada na boa-fé objetiva e na transparência que deve reger as relações de consumo – é uma forma de responsabilidade e de responsabilização.

2. Fatores especiais de vulnerabilização/fraqueza dos consumidores no digital

O novo paradigma tecnológico do mercado de consumo digital, ensina Miragem,⁷⁰ deu causa a diversas transformações nos estilos de vida e nos hábitos de consumo e, por corolário, no mercado de consumo.

⁶⁷ MIRAGEM, Bruno. Novo paradigma tecnológico, mercado de consumo digital e o direito do consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 125, set./out. 2019.

⁶⁸ Em que pese a nova confiança despertada, no que diz respeito a novas tecnologias, “a comunicação, facilitada pelas redes globais, determina uma maior vulnerabilidade daqueles que se comunicam”. (JAYME. Erik. O direito internacional privado do novo milênio: a proteção da pessoa humana face à globalização. *Cadernos do Programa de Pós-graduação em Direito da UFRGS*, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 133-146, 2003).

⁶⁹ MIRAGEM, Bruno. Novo paradigma tecnológico, mercado de consumo digital e o direito do consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 125, set./out. 2019.

⁷⁰ MIRAGEM, Bruno. Novo paradigma tecnológico, mercado de consumo digital e o direito do consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 125, set./out. 2019.

Dentre elas, o professor destaca que nenhum dos avanços foi mais relevante do que o desenvolvimento da internet, que deu uma nova dimensão (virtual e, podemos acrescentar, simbiótica) às relações que se estabelecem entre fornecedores e consumidores, como aquelas havidas no comércio eletrônico (seja próprio, de compartilhamento, ou ainda outras espécies de *marketplaces*), como também aquelas havidas pela utilização de estruturas digitais (*apps*, *sites*) promovidas por plataformas para as mais diversas finalidades, de substrato econômico ou não, como redes sociais, *streamings*, buscadores, comparadores de preços e características etc.

Ante a essa realidade de rápida e constante mutação, especialmente catalisada pela tecnologia da informação e da comunicação, bem como pelo desenvolvimento de aparatos tecnológicos com alto nível de processamento e estruturação de dados, urge repensar os conceitos e as propostas tradicionais para que a defesa do consumidor, materializada no microsistema protetivo desse sujeito em específico, continue plástica o suficiente para lidar juridicamente com novas situações emergentes que potencialmente representam prejuízos aos consumidores e seus direitos sem que, todavia, se descure de seus valores fundamentais.

Observe-se que não se está defendendo a estagnação legislativa no que concerne a eventuais atualizações do direito do consumidor no Brasil, posto que necessárias para a tutela dos consumidores nos desdobramentos da criatividade e das necessidades negociais dos agentes econômicos.

A proposta é complementar: pela dinamicidade própria do ambiente digital, em que em segundos todo um modelo de negócios, termos e condições de uso, bem como políticas de privacidade e de coleta de dados pessoais, podem ser modificados até mesmo sem prévio aviso aos interessados, caberá ao intérprete e aplicador do direito, nas lições de Miragem,⁷¹ atualizar o sentido da norma pela sua interpretação contemporizada e pela concreção de seus conceitos: “[s]itua-se aí uma das funções mais relevantes dos princípios jurídicos, em especial aqueles que caracterizam e fundamentam certa disciplina jurídica, como é o caso do princípio da vulnerabilidade em relação ao direito do consumidor”.

⁷¹ MIRAGEM, Bruno. Princípio da vulnerabilidade: perspectiva atual e funções no direito do consumidor contemporâneo. In: _____; MARQUES, Claudia; MAGALHÃES, Lúcia Ancona. *Direito do Consumidor: 30 anos do CDC – da consolidação como direito fundamental aos atuais desafios da sociedade*. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 243-261.

Nesse sentido é que o autor afirma ser necessária a apreciação das alterações da realidade social e econômica e a interpretação dessa mesma realidade, a qual é nova e reflete em reconhecimento de vulnerabilidades especializadas (digitais ou digitalizadas) dos consumidores no mercado, para a interpretação e aplicação das normas do CDC.

Diz-se especializadas pois, em nossa visão, trata-se do reconhecimento das especificações dos grandes tipos de vulnerabilidade elencados no título anterior ou então da transposição ao ambiente virtual, com as devidas particularizações, de vulnerabilidades pré-existentes (digitalizadas, codificadas), ao par da existência de outros novos reconhecimentos (vulnerabilidades digitais), especialmente no que toca a atributos personalíssimos e sensíveis dos consumidores utilizados de maneira arbitrária, incorreta ou discriminatória.

2.1. Vulnerabilidade digital estrutural: por *design* e tratamento de dados pessoais

A vulnerabilidade pode ser apreciada, lembra Miragem,⁷² por diversos ângulos, justamente por ser um conceito aberto e polissêmico, cujo teor será preenchido a partir das especificidades do caso concreto (concernentes à pessoa ou à situação específica) ou de fatores gerais típicos de mercado que determinam uma assimetria entre as partes (concernente ao mercado de consumo).

Elucidam Micklitz *et al.*⁷³ que, para entender a vulnerabilidade digital, é preciso compreender o aspecto estrutural (arquitetural) dessa vulnerabilidade que se dá nessa ambiência em específico. Para os pesquisadores, o ambiente digital (parte dele, as plataformas) é desenhado para mudar comportamentos, antecipando preconceitos (*biases*) cognitivos e afetivos no seu *design*, culminando no conceito de arquiteturas digitais de escolha (*digital choice architectures*),⁷⁴ as quais são baseadas em intensa coleta e tratamento de dados pessoais, são dinamicamente ajustáveis e otimizam essa

⁷² MIRAGEM, Bruno. Princípio da vulnerabilidade: perspectiva atual e funções no direito do consumidor contemporâneo. In: _____; MARQUES, Claudia; MAGALHÃES, Lúcia Ancona. *Direito do Consumidor: 30 anos do CDC – da consolidação como direito fundamental aos atuais desafios da sociedade*. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 243-261.

⁷³ MICKLITZ, Hans-W.; HELBERGER, Natali; STRYCHARZ, Joanna et al. *EU consumer protection 2.0: Structural asymmetries in digital consumer markets*. Bruxelas: BEUC, mar. 2021.

⁷⁴ No original: “..., digital vulnerability describes a universal state of defenselessness and susceptibility to (the exploitation of) power imbalances that are the result of increasing automation of commerce, datafied consumer-seller relations, and the very architecture of digital marketplaces.” (HELBERGER, N.; SAX, M.; STRYCHARZ, J.; MICKLITZ, H.-W. Choice Architectures in the Digital Economy: Towards a New Understanding of Digital Vulnerability, in *Journal of Consumer Policy*, dez. 2021, p. 2).

mesma arquitetura, oportunizando aos “arquitetos” aprenderem continuamente sobre a interação da pessoa nessa ambiência.

Esse processo é cíclico e não linear. Significa estabelecer que se prolonga no tempo, se ajusta, se experimenta e retorna *outputs* significativos sobre os sujeitos. Essa profundidade, alertam os referidos autores,⁷⁵ se intensifica nas relações de consumo e resulta possivelmente em exploração de vulnerabilidades e de manipulação: “[a]prendendo constantemente mais sobre as características dos consumidores e suas respostas a dicas específicas, o potencial para a manipulação eficaz também cresce”. Sobre o tema, acrescentam:

Em termos de vulnerabilidades do consumidor, essas arquiteturas de escolha digital contemporânea essencialmente oferecem uma infraestrutura para automatizar a busca contínua de exploráveis vulnerabilidades do consumidor. As práticas de ‘análise e otimização de negócios’ têm como objetivo encontrar como fazer com que os consumidores “se envolvam” com produtos e serviços e como “convertê-los” tão eficientemente quanto possível. Na prática, isso se resume à execução contínua de experimentos para descobrir qualquer tipo de tendência psicológica ou viés cognitivo ou afetivo que pode ser alavancado para o crescimento. [...]. As empresas contemporâneas não se limitam a identificar e a visar vulnerabilidades claramente observáveis e já presentes; muito pelo contrário, a verdadeira vantagem competitiva reside na capacidade de identificar e direcionar as circunstâncias pessoais e características que tornam uma pessoa vulnerável em termos de disposição [potenciais], mas que ainda não resultaram em vulnerabilidades reais e ocorrentes. (*sic*).⁷⁶

Já havíamos identificado a mercantilização de vulnerabilidades e a sua transformação em “ativos” dos fornecedores na condução do mercado de consumo.⁷⁷ Micklitz *et al.*⁷⁸ também chegam a esta consideração, quando enfatizam que, na sociedade digital, a vulnerabilidade é arquitetural porque as estruturas nas quais navegamos são programadas/projetadas para inferir (aproveitamento de vulnerabilidades) ou mesmo

⁷⁵ MICKLITZ, Hans-W.; HELBERGER, Natali; STRYCHARZ, Joanna et al. *EU consumer protection 2.0: Structural asymmetries in digital consumer markets*. Bruxelas: BEUC, mar. 2021. p. 19.

⁷⁶ MICKLITZ, Hans-W.; HELBERGER, Natali; STRYCHARZ, Joanna et al. *EU consumer protection 2.0: Structural asymmetries in digital consumer markets*. Bruxelas: BEUC, mar. 2021. p. 19.

⁷⁷ MARQUES, Claudia Lima; MUCELIN, Guilherme. Inteligência artificial e “opacidade” no consumo: a necessária revalorização da transparência para a proteção do consumidor. In: TEPELINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia. *O Direito Civil na Era da Inteligência Artificial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 411-439.

⁷⁸ MICKLITZ, Hans-W.; HELBERGER, Natali; STRYCHARZ, Joanna et al. *EU consumer protection 2.0: Structural asymmetries in digital consumer markets*. Bruxelas: BEUC, mar. 2021. p. 19.

criar ou especificar outras novas: “as vulnerabilidades [...] que os consumidores podem experimentar não são um infeliz subproduto dos mercados de consumo digitais; vulnerabilidades são o produto dos mercados de consumo digitais”.

Nesse sentido, Bioni⁷⁹ determina que a lógica do *trafe-off* da economia dos dados pessoais é traiçoeira pela peculiaridade entre gratificações imediatas e prejuízos mediatos/distantes. Na sua concepção, a ideia de sujeito dito racional e capaz de tomar decisões a respeito do controle de seus dados é posta em xeque por conta da complexidade do fluxo informacional. O titular dos dados “está em uma situação de vulnerabilidade específica em meio a uma relação assimétrica que salta aos olhos, havendo uma série de evidências empíricas a esse respeito”, defendendo até a mesmo a hipervulnerabilidade.

As vulnerabilidades, assim, são ou tornam-se *codificadas e programadas* a partir de inferências comportamentais e afetivas a partir da coleta e do tratamento de dados pessoais dos consumidores, que, segundo Mendes e Fonseca, também pode representar fatores de vulnerabilização dos sujeitos nas dinâmicas da internet.

Mendes⁸⁰ elenca pelos menos três situações em que haverá extremada vulnerabilidade do consumidor no tratamento dos dados pessoais: o consentimento aparente, a falta de transparência e os riscos de discriminação.

Sobre o primeiro, afirma que o consentimento no tema da proteção de dados é bastante complexo e enfrenta diversificadas dificuldades, especialmente considerando a sua natureza atípica, posto que possui características negociais concomitantemente possuir também caráter personalíssimo (assemelha-se a negócio jurídico sem o ser).

Agrava-se essa complexidade quando o consentimento é mais aparente que real, haja vista o consumidor ver-se, no mais das vezes, constrangido ou pressionado a consentir para que o produto ou serviço acessado não lhe seja negado, já que resiste com certa normalidade a base do *take it or leave it* (pegar ou largar), fazendo com que a liberdade de consentir reste prejudicada, bem como sua autodeterminação informativa.

⁷⁹ BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 144.

⁸⁰ MENDES, Laura Schertel. A vulnerabilidade do consumidor quanto ao tratamento de dados pessoais. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 102, p. 19-43, nov./dez. 2015.

Sobre a falta de transparência, Mendes⁸¹ ressalta a importância das avaliações de risco em relação aos consumidores e sistemas de *scores* que “pontuam” a pessoa para que tenha acesso, ou não, a determinados produtos ou serviços e, igualmente, determinando-lhe ou excluindo-lhe de oportunidades de vida. Em outros termos, fala-se da opacidade nas lógicas algorítmicas no mercado de consumo que são utilizadas em decisões automatizadas, incluindo aquelas relativas à formação de determinado perfil.⁸²

Para Mendes,⁸³ “compreende-se que caso o consumidor tenha restringido o seu acesso a determinados bens e produtos no mercado de consumo em razão desse sistema de avaliação, é fundamental que os critérios desse sistema sejam transparentes e públicos”, sob pena de violar os princípios de proteção de dados pessoais e tornar-se ilegítimo.

O terceiro fator de vulnerabilização trazido por Mendes é a discriminação algorítmica, derivação de determinadas formas de tratamento de dados que assume diversas formas (estatística, geográfica, racial etc.) e que acarreta exclusão do consumidor do mercado de consumo ou ainda sua estigmatização de acordo com características pessoais. Independentemente das bases legais, incluindo-se o consentimento, será ilegítimo *a priori* por ferir não só a Lei Geral de Proteção de Dados, como notadamente o princípio da igualdade protegido constitucionalmente.

2.2. Vulnerabilidade digital situacional: por catividade/dependência ou neuropsicológica

Caroline Meller-Hannich ensina que a noção de consumidor se caracteriza por seu ‘papel’ na sociedade, mas também por sua ‘situação’ em relação aos contratos em especial ou na sociedade (*situatives Element*).⁸⁴ Queremos aqui explorar esta ideia de uma vulnerabilidade ‘situacional-digital’, pois a liberdade do consumidor no ambiente construído online ou das plataformas não é o mesmo da liberdade de atuação no mundo físico.⁸⁵

⁸¹ MENDES, Laura Schertel. A vulnerabilidade do consumidor quanto ao tratamento de dados pessoais. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 102, p. 19-43, nov./dez. 2015.

⁸² MARQUES, Claudia Lima; MUCELIN, Guilherme. Inteligência artificial e “opacidade” no consumo: a necessária revalorização da transparência para a proteção do consumidor. In: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia. *O Direito Civil na Era da Inteligência Artificial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 411-439.

⁸³ MENDES, Laura Schertel. A vulnerabilidade do consumidor quanto ao tratamento de dados pessoais. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 102, p. 19-43, nov./dez. 2015. p. 11.

⁸⁴ MELLER-HANNICH, Caroline. *Verbraucherschutz im Schuldvertragsrecht*. Tübingen: Mohr, 2005, p. 140.

⁸⁵ MARQUES, Claudia Lima. Perspectives for consumer protection in the XXI century. *Macau Journal of Brazilian Studies*, Macau, v. 4, n. 1, Abr. 2021, p. 75 e seg.

Micklitz *et al.*,⁸⁶ no relatório da *European Consumer Organisation* (BEUC) de março de 2021, sustentam que, nos mercados digitais, todos os consumidores são potencialmente vulneráveis,⁸⁷ sendo que a “vulnerabilidade digital descreve um estado universal de impotência e suscetibilidade a (exploração de) desequilíbrios de poder que são o resultado da crescente automação do comércio, das relações consumidor-vendedor informadas e da própria arquitetura dos mercados digitais”.

O *report* também sinaliza que a União Europeia está deixando de ter uma visão ‘reducionista’ acerca da vulnerabilidade, de modo a deixar de privilegiar somente aspectos “estáticos” para abarcar aspectos relacionais e situacionais, dinâmicos, considerando o consumidor ora mais ora menos vulnerável, a depender de determinadas condições e das relações que estabelece. De acordo com o a Comissão Europeia, em seu estudo “*Consumer vulnerability across key markets in the European Union*”,⁸⁸ os consumidores podem se tornar vulneráveis na dependência de suas circunstâncias e situações. Elencam-se cinco dimensões que definem a vulnerabilidade do consumidor:

Um consumidor que, como resultado de características sociodemográficas, características comportamentais, situação pessoal ou ambiente de mercado:

- Corre maior risco de experimentar resultados negativos no mercado;
- Tem capacidade limitada de maximizar seu bem-estar;
- Tem dificuldade em obter ou assimilar informações;

⁸⁶ MICKLITZ, Hans-W.; HELBERGER, Natali; STRYCHARZ, Joanna et al. *EU consumer protection 2.0: Structural asymmetries in digital consumer markets*. Bruxelas: BEUC, mar. 2021. p. 4.

⁸⁷ É necessário frisar que na União Europeia, diferentemente do Brasil, não há uma presunção de vulnerabilidade geral dos consumidores como a do Art. 4, I do CDC. Conforme a UNGCP, o conceito de consumidor vulnerável (‘vulnerable consumer’) é restringido a determinados grupos mais fracos (crianças, pessoas com deficiência, pobres e desfavorecidos da sociedade, veja Guideline) e não é uma presunção estendida a todos os consumidores; em outros termos, em princípio, a regra é pelo entendimento do “consumidor médio” (*average consumer*). Vulneráveis seriam particularizados a partir de suas características “internas” que afetam a capacidade de lidar adequadamente com práticas comerciais. Conforme Micklitz *et al.* (MICKLITZ, Hans-W.; HELBERGER, Natali; STRYCHARZ, Joanna et al. *EU consumer protection 2.0: Structural asymmetries in digital consumer markets*. Bruxelas: BEUC, mar. 2021., p. 9), “[n]ão fazem parte da análise fatores externos, como o grau de exposição a certas práticas ou as consequências que essas práticas podem ter para um consumidor individual” – e isso reforça a preocupação sobre o reconhecimento de vulnerabilidades no ambiente digital. O art. 5º (3), da Diretiva relativa às práticas comerciais desleais (Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio de 2005) assim define: “As práticas comerciais que são susceptíveis de distorcer substancialmente o comportamento económico de um único grupo, claramente identificável, de consumidores particularmente vulneráveis à prática ou ao produto subjacente, em razão da sua doença mental ou física, idade ou credulidade, de uma forma que se considere que o profissional poderia razoavelmente ter previsto, devem ser avaliadas do ponto de vista do membro médio desse grupo. Esta disposição não prejudica a prática publicitária comum e legítima que consiste em fazer afirmações exageradas ou afirmações que não são destinadas a ser interpretadas literalmente”

⁸⁸ Veja na íntegra: UNIÃO EUROPEIA. *Consumer vulnerability across key markets in the European Union. Final Report*. 2016. Disponível em: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/consumers-approved-report_en.pdf. Acesso em: 16 ago. 2022.

- Tem menos possibilidade de comprar, escolher ou acessar produtos adequados; ou
- É mais suscetível a certas práticas de *marketing*.⁸⁹

Também com aportes da economia comportamental, Micklitz *et al.*⁹⁰ determinam que os fornecedores buscam por práticas experimentais e criativas que pretendem “otimizar” o comportamento do consumidor, quando se identifica e se visa a diferentes fontes e gatilhos de vulnerabilidade, bem como uma ampla gama de circunstâncias em que consumidores são ou se tornam vulneráveis na estrutura da internet e no ciberespaço. As vulnerabilidades tipicamente digitais podem ser reveladas a partir de abordagens distintas e aglutinadoras (como salientamos) das vulnerabilidades fáticas, jurídicas, técnicas e informacionais – com o devido destaque dado ao ciberespaço.

A vulnerabilidade informacional antes analisada, por exemplo, segundo Miragem,⁹¹ aliada ao déficit informacional do consumidor nas relações de consumo, sofre alterações nessa nova ambiência virtual, já que “não se resume à falta ou à pouca qualidade da informação prestada, mas à ausência de habilidade ou familiaridade com o ambiente digital”, que tem o condão de repercutir “tanto na interpretação das manifestações nele emitidas ou recebidas, quanto na própria capacidade de resposta adequada a seus interesses nas relações jurídicas que resultem daí”.

Fala-se, nesse sentido, em iliteracia digital, à lembrança da vulnerabilidade fática correspondente, guardadas as diferenças, por evidente, do analfabetismo (específico ou funcional) e da falta de informações concernentes à correta utilização de determinado produto ou serviço ou ainda da fruição de todas as suas utilidades.

Um fator de vulnerabilização já identificado por Moraes⁹² no mercado de consumo analógico reaparece com maior força na transformação digital em virtude de novos mecanismos de *marketing* altamente “targetizados”, hiperpersonalizados e *programados* para cada consumidor individual de acordo com seu perfil de consumo

⁸⁹ UNIÃO EUROPEIA. Understanding consumer vulnerability in the EU’s key markets. *Factsheet*. Fev. 2016. Disponível em: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/consumer-vulnerability-factsheet_en.pdf. Acesso em: 16 ago. 2022.

⁹⁰ MICKLITZ, Hans-W.; HELBERGER, Natali; STRYCHARZ, Joanna et al. *EU consumer protection 2.0: Structural asymmetries in digital consumer markets*. Bruxelas: BEUC, mar. 2021.

⁹¹ MIRAGEM, Bruno. Princípio da vulnerabilidade: perspectiva atual e funções no direito do consumidor contemporâneo. In: _____; MARQUES, Claudia; MAGALHÃES, Lúcia Ancona. *Direito do Consumidor: 30 anos do CDC – da consolidação como direito fundamental aos atuais desafios da sociedade*. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 243-261.

⁹² MORAES, Paulo Valério Dal Pai. *Código de Defesa do Consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade, na oferta, nas demais práticas comerciais*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 166.

específico. Para este autor, trata-se da vulnerabilidade neuropsicológica: “a reiteração e enorme gama de dados também possui a capacidade de confundir, estimular determinadas reações e, em alguns casos, inclusive alienar os mais vulneráveis”, cujo resultado poderá ser até mesmo “a incorreta tomada de decisão”.

Miragem afirma que a vulnerabilidade neuropsicológica⁹³ (ou comportamental, de acordo com Verbicaro e Caçapietra⁹⁴) se dá a partir de estímulos sensoriais ou emocionais emitidos pelo meio digital (sons, fotos, vídeos, cores, velocidade de *frames* etc.⁹⁵) e as respostas dos consumidores, bem como a partir das inferências da economia comportamental, que reconduzem, segundo Kaiser,⁹⁶ a gatilhos fundamentais humanos⁹⁷ a partir de uma estrutura de incentivos (*nudges*), que possivelmente reduzem as cautelas relativas às prestações pactuadas⁹⁸ e o acesso aos diversos serviços disponibilizados ou oferecidos *online*.

Outro componente que contribui à vulnerabilidade ‘neuropsicológica’ digital do consumidor é a estratégia utilizada pelas plataformas concernentes à *gamificação*. Conforme refletimos,⁹⁹ a gamificação permite intensificar o tempo de permanência e de atenção de seus usuários por meio de experiências envolventes, utilizando-se de princípios de *design* de jogos inclusive para a tomada de decisão, como narrativas, senso de comunidade, recompensas, reputação, reconhecimento e punição. Tal se dá com o fim de induzir um comportamento (pré)estipulado por programação, potencialmente manipulando comportamentos e minando a autonomia da vontade: torna-se possível

⁹³ Veja sobre estes fatores que afetam o comportamento e a psiquê do consumidor: CARVALHO, Alexander Perazo Nunes de; SOUSA, Raphaella Prado Aragão de, A influência da psicopolítica digital nas contratações virtuais e seus reflexos no aumento da vulnerabilidade do consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, vol. 123/2019, p. 289 – 309, Maio - Jun / 2019.

⁹⁴ VERBICARO, Dennis; CAÇAPIETRA, Ricardo dos Santos. Economia comportamental no desenho de políticas públicas de consumo através dos nudges. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 133, p. 385-411, jan./fev. 2021.

⁹⁵ “É que a nova linguagem visual, fluida, rápida, agressiva, pseudoindividual e massificada dos negócios jurídicos de consumo à distância pela Internet propõe desafios sérios para o Direito Privado, em especial para o Direito do Consumidor e o seu paradigma moderno da ‘boa-fé’ nas relações contratuais”. (MARQUES, Claudia Lima. *Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do Consumidor*: um estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 46).

⁹⁶ KAISER, Brittany. *Manipulados*: como a Cambridge Analytica e o Facebook invadiram a privacidade de milhões e botaram a democracia em xeque. Rio de Janeiro: Harper Collins, 2020.

⁹⁷ Assim, conforme Schmidt Neto: “Hoje a psicologia cognitiva busca responder como o homem compreende o mundo e de que modo reage a ele buscando adaptá-lo a si. Na sociedade de consumo, tal conhecimento do comportamento serve também à manipulação do comportamento de outros indivíduos na busca de resultados econômicos”. (SCHMIDT NETO, André Perin. *Contratos na sociedade de consumo*: vontade e confiança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. [e-book]).

⁹⁸ MIRAGEM, Bruno. Princípio da vulnerabilidade: perspectiva atual e funções no direito do consumidor contemporâneo. In: _____; MARQUES, Claudia; MAGALHÃES, Lúcia Ancona. *Direito do Consumidor*: 30 anos do CDC – da consolidação como direito fundamental aos atuais desafios da sociedade. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 243-261.

⁹⁹ MUCELIN, Guilherme; STOCKER, Leonardo. *Relações trabalhistas ou não trabalhistas na economia do compartilhamento*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. p. 335.

que, por meio da exploração da “vulnerabilidade digital, aliada à técnica e à informacional, impositiva de certo grau de alienação do participante, sejam tomadas decisões direcionadas/influenciadas pela plataforma”.

Outro possível enfoque para a vulnerabilidade digital se relaciona com a situação de *dependência/catividade* em relação à manutenção¹⁰⁰ ou ao acesso a determinado serviço ou a produto inteligente prestado e oferecido por plataformas, que se pode considerar como uma condição, na análise de cada caso, para a fruição plena da vida e de autorrealização na sociedade contemporânea.¹⁰¹

Como afirmamos¹⁰², nesses contratos de trato sucessivo a relação é movida pela busca de uma segurança, pela busca de uma futura prestação, *status* ou de determinada qualidade nos serviços, o que reduz o consumidor a uma posição de “cativo” – cliente do fornecedor e de seu grupo de colaboradores ou agentes econômicos. A posição de dependência de ‘catividade’ só pode ser entendida no exame do contexto das relações atuais, em que determinados serviços prestados no mercado asseguram (ou prometem) ao consumidor e a sua família “*status*”, “segurança”, “crédito renovado”, “escola ou formação universitária certa e qualificada”, “moradia assegurada”, “lazer” ou mesmo “saúde” ou “informação” no futuro.

Aqui se aproxima da vulnerabilidade fática ou socioeconômica dos antigos ‘monopólios’ de serviços públicos, em especial face à nova essencialidade social destes produtos e serviços privados digitais.¹⁰³ O STJ,¹⁰⁴ em um caso que *não* envolvia plataformas, considerou esse atributo como indicativo de vulnerabilidade. Tratava-se de uma lide de

¹⁰⁰ A catividade geralmente é no tempo, veja: MARQUES, Claudia Lima. Contratos cativos de longa duração e a exceção da ruína: tempo, boa-fé, catividade e confiança. In MARQUES, Claudia Lima; LORENZETTI, Ricardo Luis; CARVALHO, Diógenes Faria de; MIRAGEM, Bruno. *Contratos de serviços em tempos digitais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 452 e seg.

¹⁰¹ No Referendo na Medida Cautelar na ADI n. 6.389-DF, o sr. Ministro Gilmar Mendes afirma que as novas tecnologias se tornaram condição necessária tanto para a vivência em sociedade – no sentido de que as pessoas são obrigadas a utilizar dessas tecnologias para não serem marginalizadas econômica e socialmente – quanto para a realização de direitos – como liberdade de expressão –, ao passo que, simultaneamente, “esses mesmos avanços tecnológicos suscitam riscos generalizados de violação de direitos fundamentais básicos”, dentre os quais o Ministro destacou a igualdade. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.389. Requerente: Partido Socialista Brasileiro. Interessado: Presidente da República. Relatora: Min. Rosa Weber. Brasília, 07 maio 2020. DJe 12 nov. 2020.).

¹⁰² MARQUES, Claudia Lima. Revisando a teoria geral dos serviços com base no Código de Defesa do Consumidor em tempos digitais. In: _____; LORENZETTI, Ricardo Luis; CARVALHO, Diógenes Faria de; MIRAGEM, Bruno. *Contratos de serviços em tempos digitais: contribuição para uma nova teoria geral dos serviços e princípios de proteção dos consumidores*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. [e-book]

¹⁰³ Veja sobre a vulnerabilidade fática, nos contratos privados e administrativos e privatizados com consumidores: MARQUES, Claudia Lima. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 320 e seg.

¹⁰⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 476.428. Recorrente: Agipliquigás S.A. Recorrido: Gracher Hotéis e Turismo Ltda. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Brasília, 19 abr. 2005. DJ 09 maio 2005.

um hotel contra fornecedor de gás, com o objetivo de ser ressarcido pelos prejuízos advindos da impossibilidade de utilização das sobras de GLP remanescentes nos recipientes, as quais eram devolvidas à fornecedora (Recurso Especial n. 476.428). Debateu-se se o hotel poderia ser considerado consumidor da fornecedora de gás, mesmo não sendo, tecnicamente, destinatário final fático e econômico do produto adquirido contínua e sistematicamente.

A teoria da interpretação do conceito de consumidor, em regra, é a finalista,¹⁰⁵ que não admite, em princípio, empresas qualificando-se juridicamente enquanto tal. Todavia, a teoria finalista é temperada, aprofundada em casos difíceis, quando existir, no caso concreto, a vulnerabilidade de um contratante perante um fornecedor.

Como consta no acórdão,¹⁰⁶ a Min. Nancy Andrighi constatou que a vulnerabilidade não se define, ou melhor, não se reconhece a partir apenas da capacidade econômica das partes, do nível de informação ou cultura ou valor do contrato firmado: “Todos esses elementos podem estar presentes e o comprador ainda ser vulnerável pela dependência do produto”, aduzindo que existem outros elementos indicativos, dentre os quais, interessante para nós no que toca às plataformas, encontra-se a extremada necessidade do bem ou serviço e as *exigências da modernidade* atinentes à atividade. Reconheceu-se, na hipótese, também a vulnerabilidade fática, jurídica e técnica do hotel que agia fora de sua especialidade, bem como a sua exposição às práticas comerciais do fornecedor, motivo pelo qual foi enquadrado como consumidor.

Ao analisar esse caso, Miragem¹⁰⁷ determina que haverá situações que são típicas de mercado e não se confundem com necessidades de consumo ou com a posição subjetiva

¹⁰⁵ Essa corrente interpretativa “[s]ustenta que o conceito de consumidor deve ser estabelecido de acordo com o critério do art. 2º do CDC, a partir da noção de destinatário final fático e econômico de um produto ou serviço. Em outros termos, de que o consumidor é aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço de modo a exaurir sua função econômica, da mesma forma como, ao fazê-lo, determina com que seja retirado do mercado de consumo. O elemento característico desta interpretação é o fato de não haver finalidade da obtenção de lucro em uma dada relação jurídica, nem de insumo ou incremento a uma determinada atividade negocial, assim como a completa exaustão da função econômica do bem, pela sua retirada do mercado. Nesta visão, o consumidor seria aquele que adquire o produto ou o serviço para a satisfação de interesse próprio ou de sua família. Seria, portanto, o não profissional, não especialista, a quem o direito deve proteger, na sua relação com um profissional que atua no mercado daí, porque afasta o conceito de consumidor a relação entre parceiros para um empreendimento comum, ou ainda entre dois iguais, não-profissionais, a qual se deverá aplicar o Código Civil”. (MIRAGEM, Bruno. *Curso de Direito do Consumidor*. 8. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. [e-book]).

¹⁰⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 476.428. Recorrente: Agipliquigás S.A. Recorrido: Gracher Hotéis e Turismo Ltda. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Brasília, 19 abr. 2005. DJ 09 maio 2005.

¹⁰⁷ MIRAGEM, Bruno. *Curso de Direito do Consumidor*. 8. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. [e-book].

de consumo, mas de fatos que se encontravam em domínios de outras disciplinas jurídicas, como o direito da concorrência e o direito empresarial.

Transpondo, com as devidas precauções a dependência, ao direito do consumidor digital, mais especificamente ao consumidor pessoa natural fora de suas capacidades empreendedoras, podemos concluir¹⁰⁸ que “pode ser um indicador da conexidade de relações contratuais (de consumo) e da vulnerabilidade *in concreto*, por exemplo, a posição de catividade, sujeição e dependência no tempo que esteja reduzido um dos cocontratantes”.

Uma conta de *e-mail*, por exemplo, típico serviço prestado por aplicações de internet, poderá determinar uma dependência do consumidor e sua catividade com relação àquele determinado portal, posto que todos os correios eletrônicos e demais comunicações ficam salvas no servidor daquele fornecedor, sob pena de perder todos os documentos, comunicações, fotos etc.

Ou ainda, quando a reputação de determinado consumidor,¹⁰⁹ a qual contribui para o estabelecimento de relações jurídicas na economia do compartilhamento, por exemplo, está adstrita a determinada conta em aplicativo específico, ressalvados os casos de portabilidade,¹¹⁰ se possível. Outra situação de dependência poder-se-ia dar em relação aos aplicativos que monitoram a saúde do consumidor doente, seja por *wearables* (*smartwatches*), seja pelo *smartphone/tablet* ou mesmo para monitoração remota por familiar ou responsável. Para Mendes e Fonseca:¹¹¹

¹⁰⁸ MARQUES, Claudia Lima. Contratos cativos de longa duração e a exceção da ruína: tempo, boa-fé, catividade e confiança. in _____; LORENZETTI, Ricardo Luis; CARVALHO, Diógenes Faria de; MIRAGEM, Bruno. *Contratos de serviços em tempos digitais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 447-488.

¹⁰⁹ Sobre o tema, Teubner *et al.* (TEUBNER, Timm et al. Understanding the platform economy: signals, trust, and social interaction. In: *Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences*. Havaí, 2020. p. 5146) ensinam: “Trust and reputation among users of two-sided platforms are imperative for flourishing markets. The process of building and maintaining trust is hence of utmost importance to platforms”.

¹¹⁰ “Associado ao custo de troca (e também aos custos de procura) está o efeito de aprisionamento, que é a situação na qual o consumidor torna-se dependente de um fornecedor de produto e serviço e não consegue migrar para outro sem custos de transação substanciais ou sem inconveniências, como os custos especificados acima. Portanto, o lock-in é o efeito de permanência do consumidor ao fornecedor originário mesmo quando haja um desejo pela mudança, que pode ser proveniente do aumento de preços, falhas, vícios ou defeitos no fornecimento do produto ou serviço, vazamento de dados ou falta de privacidade. No entanto, quando esse consumidor faz um cálculo do custo-benefício de uma eventual troca, percebe que será mais custoso, seja monetariamente, seja emocionalmente, seja em termos de conforto, trocar para um fornecedor alternativo”. (CRAVO, Daniela Copetti. *Direito à portabilidade de dados: interface entre a defesa da concorrência, do consumidor e proteção de dados*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 71-72).

¹¹¹ MENDES, Laura Schertel; FONSECA, Gabriel Campos Soares da. Proteção de dados para além do consentimento: tendências de materialização. In: DONEDA, Danilo et. al. (coords). *Tratado de proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 90-112. p. 97.

Nessas situações, a decisão individual de consentir não é livre e autônoma ou oriunda da avaliação dos ônus e dos bônus envolvidos. Ao revés, ela se origina de uma verdadeira imposição estabelecida por terceiro: consentir ou simplesmente não desfrutar de serviço/produto, que, muitas vezes, sob a perspectiva do indivíduo, é essencial para a sua sociabilidade ou acesso à informação na era digital.

Conforme asseveram Micklitz *et al.*,¹¹² “[o]utra consideração importante é a natureza frequentemente assimétrica de relações comerciais duradouras”, de forma que, “[à] medida que os consumidores continuam usando os mesmos serviços, aplicativos ou plataformas ao longo do tempo, as entidades comerciais que oferecem esses serviços, aplicativos ou plataformas serão capazes de coletar e analisar mais dados do usuário”, resultando na capacidade de “identificar vulnerabilidades exploráveis”.

A vulnerabilidade do consumidor não deixa de representar – como sempre foi – um valor latente de potencial exploração de fraquezas do sujeito que consome. A diferença é que, no mundo digital, esse “valor” é muito mais facilmente percebido e revelado, ou mesmo criado, por conta das arquiteturas de escolha, da automação do mercado, das grandes plataformas-fornecedoras e do engajamento constante dos consumidores em uma internet cada vez mais ubíqua, onisciente e onipresente – o que demanda a evolução no conceito de *vulnerabilidade... agora digital*.

Considerações finais

Conclua-se que a vulnerabilidade do consumidor é um conceito em constante evolução. E, esta evolução ocorre no mercado de consumo, em quaisquer de seus “formatos” – analógico, digital, simbiótico, a exemplo da introdução da figura do assédio de consumo no CDC pela Lei 14.181/2021 complementando a figura do abuso de fraqueza do Art. 39, IV do CDC. Pedra de toque do direito do consumidor, esta noção polifórmica e mutável da vulnerabilidade (Art. 4º, I do CDC), permite flexibilidade e assegura que o Direito do Consumidor nacional se apresente com plasticidade o suficiente para que novas situações sejam tuteladas pelo e dentro dos limites do microsistema protetivo do CDC, que se transversaliza no ambiente *online* em compasso com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o Marco Civil da Internet e demais leis futuras, como o Marco Civil da Inteligência Artificial.

¹¹² MICKLITZ, Hans-W.; HELBERGER, Natali; STRYCHARZ, Joanna et al. *EU consumer protection 2.0: Structural asymmetries in digital consumer markets*. Bruxelas: BEUC, mar. 2021. p. 20.

Na economia digital, o tratamento dos dados pessoais dos consumidores titulares serve, de acordo com sua finalidade (nem sempre clara ou informada) tanto para excluir quanto para incluir o consumidor no novo paradigma tecnológico atinente ao consumo.¹¹³ Aspectos subjetivos, da própria pessoa, bem como objetivos, atinentes a produtos, serviços e contratos, passam a contar com uma complexidade maior em atenção ao ambiente virtual, por conta de suas peculiaridades e de suas estruturas.

Fineman¹¹⁴ destaca que o ponto central de uma teoria da vulnerabilidade, nesse sentido, deve ir além do indivíduo e das características individuais para também abarcar as estruturas sociais e as características das instituições e das relações que possivelmente contribuam para a vulneração do sujeito, como (exemplificamos) as do ambiente digital, a fim de que se encontrem meios para que seja diminuída e a economia de plataformas não represente desencontro com os interesses da sociedade nem com os seus valores fundantes constitucionalmente protegidos.

Foram vistas e correlacionadas, ao longo do estudo, as vulnerabilidades tradicionais dos consumidores e aquelas específicas ou especializadas em meio digital, que colocam o consumidor em uma posição ainda mais de vulnerabilidade ou, como tantos defendem, em uma vulnerabilidade agravada. As considerações feitas na pesquisa, com relação ao mundo *online*, foram construídas pela dogmática do Direito do Consumidor, o qual desenvolve a temática da vulnerabilidade por conta do reconhecimento expresso, no CDC, desse atributo elevado a princípio, bem como por conta de seu caráter civilizatório no que tange à busca do nivelamento de desequilíbrios que se materializam no mercado de consumo – e, no digital, também além de suas fronteiras.

Referências

ADAM, Leonie; MICKLITZ, Hans-W. Verbraucher und Online-Plattformen, in MICKLITZ, Hans-W. et alli (Hrsg.). Verbraucherrecht 2.0 – Verbraucher in der digitalen Welt, Nomos: Baden-Baden, 2017, p. 45-102.

AZEVEDO, Fernando Costa de; KLEE, Antonia Espíndola Longoni. Considerações sobre a proteção dos consumidores no comércio eletrônico e o atual processo de atualização do Código de Defesa do Consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, n. 85, p. 209- 260, jan.-fev. 2013.

AZEVEDO, Fernando Costa de; SANTOS, Karinne E. G. dos.; MOREIRA, Tássia Rodrigues. Vulnerabilidade dos consumidores na sociedade da informação e necessidade da proteção jurídica

¹¹³ Veja, por todos, MIRAGEM, Bruno. Discriminação injusta e o direito do consumidor, in BENJAMIN, Antonio H; MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. *O Direito do consumidor no mundo em transformação*, São Paulo: RT, 2021, p. 203-230.

¹¹⁴ FINEMAN, Martha Albertson. Vulnerability and inevitable inequality. *Oslo Law Review*, Escandinávia, v. 4, n. 3-2017, 2017, p. 133-149.

de seus dados nas relações estabelecidas em ambiente digital, in *Revista de Direito do Consumidor*, vol. 141/2022, p. 201 – 218, Maio - Jun / 2022.

BAKER, Stacey Menzel; LA BARGE, Monica; BAKER, Courtney Nations. Consumer vulnerability: Foundations, phenomena, and future investigations. In: HAMILTON, Kathy; DUNNET, Susan; PIACENTINI, Maria (eds.). *Consumer vulnerability: conditions, contexts and characteristics*. London/New York: Routledge, 2016. p. 13-30.

BERGSTEIN, Laís. *O tempo do consumidor e o menosprezo planejado*. São Paulo, RT, 2019.

BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

BORGES, Gustavo; FILÓ, Maurício da Cunha Savino. Consumo, publicidade e inteligência artificial: (necessários) limites à tecnologia persuasiva no constante assédio do consumidor, in *Revista de Direito do Consumidor*, vol. 136/2021, p. 201 – 232, Jul - Ago / 2021.

BUDNITZ, Mark E. Principles and Programs to Protect consumers from the Deleterious Effects of Technological Innovation, in WEI, Dan; NEHF, James P.; MARQUES, Claudia Lima. *Innovation and the Transformation of Consumer Law*, Springer-SSAP, Cham, 2020, p. 3-18.

CALAIS-AULOY, Jean; TEMPLE, Henri. *Droit de la consommation*. Paris: Daloz, 2010.

CARVALHO, Alexander Perazo Nunes de; SOUSA, Raphaella Prado Aragão de, A influência da psicopolítica digital nas contratações virtuais e seus reflexos no aumento da vulnerabilidade do consumidor, in *Revista de Direito do Consumidor*, vol. 123/2019, p. 289 – 309, Maio - Jun / 2019

CRAVO, Daniela Copetti. *Direito à portabilidade de dados: interface entre a defesa da concorrência, do consumidor e proteção de dados*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

DO CANTO, Rodrigo Edelwein. Direito do consumidor e vulnerabilidade no meio digital, in *Revista de Direito do Consumidor*, vol. 87/2.013, p. 179 – 210, Maio - Jun / 2013.

FINEMAN, Martha Albertson. Vulnerability and inevitable inequality. *Oslo Law Review*, Escandinávia, v. 4, n. 3-2017, 2017, p. 133-149.

HAMILTON, Kathy; DUNNET, Susan; PIACENTINI, Maria. Introduction. In _____; _____; _____ (eds.). *Consumer vulnerability: conditions, contexts and characteristics*. London/New York: Routledge, 2016. p. 1-10. p. 1.

HELBERGER, N.; SAX, M.; STRYCHARTZ, J.; MICKLITZ, H.-W. Choice Architectures in the Digital Economy: Towards a New Understanding of Digital Vulnerability, in *Journal of Consumer Policy*, (Dez 2021), online. (citado MICKLITZ et al.)

HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. *Teoria geral do direito digital: transformação digital, desafios para o Direito*. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

INCARDONA, Rossella; PONCIBÒ, Cristina. The average consumer, the unfair commercial practices directive, and the cognitive revolution. *Journal of consumer policy*, v. 30, n. 1, p. 21-38, 2007.

JAYME, Erik. O direito internacional privado do novo milênio: a proteção da pessoa humana face à globalização. *Cadernos do Programa de Pós-graduação em Direito da UFRGS*, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 133-146, 2003.

JAYME, Erik. Visões para uma teoria pós-moderna do direito comparado. In *Revista dos Tribunais* 759, p. 24-40, jan. 1999 (Trad. Claudia Lima Marques).

KAISER, Brittany. *Manipulados: como a Cambridge Analytica e o Facebook invadiram a privacidade de milhões e botaram a democracia em xeque*. Rio de Janeiro: Harper Collins, 2020.

LESSIG, Lawrence. *Code: version 2.0*. New York: Basic Books, 2006.

MARQUES, Claudia Lima. *Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do Consumidor: um estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

MARQUES, Claudia Lima. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

MARQUES, Claudia Lima. Contratos cativos de longa duração e a exceção da ruína: tempo, boa-fé, catividade e confiança. in _____; LORENZETTI, Ricardo Luis; CARVALHO, Diógenes Faria de; MIRAGEM, Bruno. *Contratos de serviços em tempos digitais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 447-488.

MARQUES, Claudia Lima. Perspectives for consumer protection in the XXI century. *Macau Journal of Brazilian Studies*, Macau, v. 4, n. 1, Abr. 2021, p. 73-86.

MARQUES, Claudia Lima. Revisando a teoria geral dos serviços com base no Código de Defesa do Consumidor em tempos digitais. In: _____; LORENZETTI, Ricardo Luis; CARVALHO, Diógenes Faria de; MIRAGEM, Bruno. *Contratos de serviços em tempos digitais: contribuição para uma nova teoria geral dos serviços e princípios de proteção dos consumidores*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. [e-book]

MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. “Serviços simbióticos” do consumo digital e o PL 3.514/2015 de atualização do CDC. 2020. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 132, p. 91-118, nov./dez. 2020. E, republicado, in _____; LORENZETTI, Ricardo Luis; CARVALHO, Diógenes Faria de; MIRAGEM, Bruno. *Contratos de serviços em tempos digitais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 391-424.

MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. *O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MARQUES, Claudia Lima; MUCELIN, Guilherme. A teoria do finalismo aprofundado no STJ: um exame sobre a vulnerabilidade a partir do caso concreto. In: MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe; MIRAGEM, Bruno (coords.). *Teses jurídicas dos tribunais superiores: Direito do Consumidor*. T. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 25-38.

MARQUES, Claudia Lima; MUCELIN, Guilherme. Inteligência artificial e “opacidade” no consumo: a necessária revalorização da transparência para a proteção do consumidor. In: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia. *O Direito Civil na Era da Inteligência Artificial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 411-439.

MARQUES, Claudia Lima; MUCELIN, Guilherme. Novo mercado de consumo ‘simbiótico’ e a necessidade de proteção de dados dos consumidores. In: SARLET, Gabrielle Bezerra Sales; TRINDADE, Manoel Gustavo Neubarth; MELGARÉ, Plínio. *Proteção de dados: temas controvertidos*. Indaiatuba: Foco, 2021. p. 67-94.

MARQUES, Claudia Lima; MUCELIN, Guilherme. Transformação digital no Brasil: Estrutura jurídica para a promoção da confiança. In: THEMOTEO, Reinaldo J. (Org.). *Reavivando e reforçando os diálogos entre Brasil e Europa*. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2021. p. 187-202.

MARQUES, Claudia Lima; PFEIFFER, Roberto. Dissemination of Consumer Law and Policy in Brazil: The Impact of EU Law. In *Journal of Consumer Policy*, vol. 45, p. 27-48 (2022).

MARTINS, Fernando Rodrigues; LIMA, Thainá Lopes Gomes Lima. Da vulnerabilidade digital à curiosa “vulnerabilidade empresarial”, in *Revista de Direito do Consumidor*, vol. 128/2020, p. 119 – 161, Mar - Abr / 2020.

MELLER-HANNICH, Caroline. *Verbraucherschutz im Schuldvertragsrecht*. Tübingen: Mohr, 2005.

MENDES, Laura Schertel. A vulnerabilidade do consumidor quanto ao tratamento de dados pessoais. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 102, p. 19-43, nov./dez. 2015.

MENDES, Laura Schertel; FONSECA, Gabriel Campos Soares da. Proteção de dados para além do consentimento: tendências de materialização. In: DONEDA, Danilo et. al. (coords). *Tratado de proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 90-112.

MICKLITZ, Hans-W.; HELBERGER, Natali; STRYCHARZ, Joanna et al. *EU consumer protection 2.0: Structural asymmetries in digital consumer markets*. Bruxelas: BEUC, mar. 2021.

MICKLITZ, Hans-W. et alli (Hrsg.). *Verbraucherrecht 2.0 – Verbraucher in der digitalen Welt*, Nomos: Baden-Baden, 2017.

MIRAGEM, Bruno. *Curso de Direito do Consumidor*. 8. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. [e-book].

MIRAGEM, Bruno. Novo paradigma tecnológico, mercado de consumo digital e o direito do consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 125, set./out. 2019.

MIRAGEM, Bruno. Princípio da vulnerabilidade: perspectiva atual e funções no direito do consumidor contemporâneo. In: _____; MARQUES, Claudia; MAGALHÃES, Lúcia Ancona. *Direito do Consumidor: 30 anos do CDC – da consolidação como direito fundamental aos atuais desafios da sociedade*. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 243-261.

MIRAGEM, Bruno. Discriminação injusta e o direito do consumidor, in BENJAMIN, Antonio H; MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. *O Direito do consumidor no mundo em transformação*, São Paulo: RT, 2021, p. 203-230.

MORAES, Paulo Valério Dal Pai. *Código de Defesa do Consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade, na oferta, nas demais práticas comerciais*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

MUCELIN, Guilherme; D'AQUINO, Lúcia Souza. O papel do direito do consumidor para o bem-estar da população brasileira e o enfrentamento à pandemia de COVID-19. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 129, p. 17-46, maio/jun. 2020.

MUCELIN, Guilherme; STOCKER, Leonardo. *Relações trabalhistas ou não trabalhistas na economia do compartilhamento*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. (no prelo).

PASQUALE, Frank. *The black box society*. Cambridge/London: Harvard University Press, 2015.

RIEFA, Christine. Coronavirus as a catalyst to transform consumer policy and enforcement. *Journal of consumer policy*, v. 43, n. 3, p. 451-461, 2020.

SCHMIDT NETO, André Perin. *Contratos na sociedade de consumo: vontade e confiança*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. [e-book]

SRNICEK, Nick. *Platform capitalism*. Cambridge: Polity Press, 2017.

TEUBNER, Timm *et al.* Understanding the platform economy: signals, trust, and social interaction. In: *Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences*. Havaí, 2020.

VERBICARO, Dennis; CAÇAPIETRA, Ricardo dos Santos. Economia comportamental no desenho de políticas públicas de consumo através dos nudges. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 133, p. 385-411, jan./fev. 2021.

WEI, Dan; NEHF, James P.; MARQUES, Claudia Lima. *Innovation and the Transformation of Consumer Law*, Springer-SSAP, Cham, 2020.

ZUBOFF, Shoshana. *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. New York: Public Affairs, 2019.

Como citar:

MARQUES, Claudia Lima; MUCELIN, Guilherme. Vulnerabilidade na era digital: um estudo sobre os fatores de vulnerabilidade da pessoa natural nas plataformas, a partir da dogmática do Direito do Consumidor. **Civilistica.com**. Rio de Janeiro, a. 11, n. 3, 2022. Disponível em: <<http://civilistica.com/vulnerabilidade-na-era-digital/>>. Data de acesso.



civilistica.com

Recebido em:

11.8.2022

Aprovado em:

30.11.2022